

CONTRATOS EN GENERAL

CAPÍTULO VII - OBJETO

1. Concepto

El objeto de los contratos es la prestación prometida por las partes, el bien o el hechos obre los que recae la obligación contraída.

Este elemento esencial del contrato no puede ser estudiado exclusivamente con las normas establecidas por el Código Civil y Comercial, en el capítulo 5, del Título II, del Libro III (arts. 1003/11), pues el propio artículo 1003 dispone que se aplican al objeto del contrato las disposiciones de la sección 1ª, capítulo 5, título IV, del Libro Primero de mismo Código.

Por lo tanto, abordaremos este tema teniendo en cuenta ambas partes del referido ordenamiento legal.

2. Prestaciones que pueden ser objeto de los contratos

Como regla, toda prestación puede ser objeto del contrato.

En línea con la precedente afirmación, **el Código Civil y Comercial ha establecido, de manera expresa, aquellas prestaciones que no pueden ser objeto del contrato.**

Ellas son el hecho imposible o prohibido por la ley, o que sea contrario a la moral y al orden público, o que sea lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad de la persona humana. Tampoco puede serlo un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea (arts. 279 y 1004).

Añade el artículo 279 que el hecho tampoco puede ser contrario a las buenas costumbres. Por su parte, el artículo 1004 agrega que si el contrato tiene por objeto derechos sobre el cuerpo humano, se deben aplicar los artículos 17 y 56. Estas normas disponen: i) que las partes del cuerpo humano carecen de valor comercial; ii) que pueden ser disponibles por el titular solo si se respeta un valor afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social; iii) que el contrato debe ajustarse a lo que dispongan las leyes especiales, y iv) que están prohibidos los actos de disposición sobre el propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad o resulten contrario a la ley, la moral, o las buenas costumbres, excepto que sean requeridos para mejorar la salud de la persona y, excepcionalmente, de otra persona, de conformidad con lo que dispone el ordenamiento jurídico.

Por lo tanto, volvemos a reiterar que toda prestación puede ser objeto del contrato, a menos que encuadre en alguna de las prohibiciones expuestas precedentemente.

Asimismo, se establece que el objeto debe ser determinado o determinable, posible, lícito, susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes, aun cuando éste no sea patrimonial (art. 1003).

Analicemos estos caracteres del objeto.

3. La determinación del objeto

El objeto debe ser determinado o determinable. No sería posible constreñir al deudora la entrega de una cosa o al cumplimiento de un hecho si no se puede precisar cuál es la cosa o hecho debido. Muchas veces, el objeto es precisado en su *individualidad*, identificando –por ejemplo– un cuerpo cierto (así, el departamento de la calle Solís 944, piso 1º, CABA). El objeto es, en estos casos, determinado.

Además del caso referido, el Código Civil y Comercial considera también que el objeto es determinado cuando solo se precisa su especie o género, según sea el caso, aunque no lo esté en su cantidad si esta puede ser determinada (art. 1005). En efecto, puede ser suficiente limitarse a indicar la cosa, si ella es fungible, siempre que exista la posibilidad de determinar la cantidad por otra vía. Es el supuesto de las cosas que tienen un valor de cotización en el mercado. Por ejemplo, si se celebra un contrato que tiene por objeto adquirir soja, por la que se pagará la suma de \$ 1.000.000, y se indica que se tomará el precio de pizarra en el puerto de Rosario, es claro que objeto del contrato ha quedado perfectamente determinado, pues bastará conocer el precio de la tonelada de soja en el mencionado puerto para, mediante una sencilla operación aritmética, establecer la cantidad adquirida. En cambio, resulta inconcebible celebrar un contrato de compraventa que verse sobre "un inmueble", sin precisar de qué inmueble se trata. El objeto, en este último caso, estaría claramente indeterminado.

La parte final del artículo 1005 añade el supuesto de *objeto determinable*. El objeto es determinable cuando se establecen los criterios suficientes para su individualización, para su determinación. Así ocurre, por ejemplo, cuando la determinación del objeto se ha dejado librada al arbitrio de un tercero; en ese caso el contrato conserva su validez aun cuando el tercero: i) no haya hecho la elección (sea que no pudo, sea que no quiso, sea que era imposible), o ii) no haya observado los criterios expresamente establecidos por las partes o por los usos y costumbres. En estos casos, puede recurrirse a la determinación judicial: el juez deberá precisar el objeto, haciéndose asesorar por peritos si fuere necesario, y tramitando el pedido por el procedimiento más breve que fije la ley local (art. 1006). Cabe añadir que si se puede dejar librada a un tercero la determinación del objeto, con mayor razón todavía, podrá dejarse librado a su criterio la fijación del precio, siguiendo idénticas pautas.

Desde luego, es necesario que las partes designen concretamente al tercero que deberá llevar a cabo la determinación del objeto. Si, en cambio, se hiciera referencia meramente a que un tercero determinará el objeto, es claro que el objeto deviene indeterminado por la imposibilidad de saber quién lo puede precisar.

4. La posibilidad del objeto

El objeto debe ser posible. En efecto, nadie puede ser obligado a pagar o hacer algo imposible. Pero la imposibilidad que anula el contrato debe ser *absoluta*. No basta que lo sea solo para un deudor determinado, por falta de aptitudes o capacidad personales o por otras razones circunstanciales. Es necesaria una total *imposibilidad física* (por ej., tocar el cielo con la mano) o *jurídica* (por ej., prender una cosa inmueble). Si una persona que carece de condiciones artísticas se obliga a realizar un retrato o una escultura, no podrá alegar más tarde la ineficacia de la obligación por su imposibilidad de cumplir la tarea que ha prometido, porque en términos absolutos, hacer un retrato o una escultura es perfectamente posible; la obligación no será nula sino que se resolverá en el pago de daños causados.

Un supuesto de imposibilidad es el de la inexistencia de la cosa prometida en el contrato: el contrato es nulo, no producirá efecto alguno. Esta solución, expresamente prevista para el contrato de compraventa (art. 1130), es aplicable a cualquier contrato. Sin embargo, si el que ha prometido la cosa sabía que ya no existía, ha obrado de mala fe, con dolo (art. 1724) y, si bien el contrato será nulo, deberá reparar los daños sufridos por la otra parte.

Por último, el Código plantea un supuesto de imposibilidad inicial, pero de posibilidad sobreviniente. En efecto, el artículo 280 dispone que *el acto jurídico sujeto a plazo o condición suspensiva es válido, aunque el objeto haya sido inicialmente imposible, si deviene posible antes del vencimiento del plazo o del cumplimiento de la condición*. En otras palabras, cuando se trata de un contrato sujeto a plazo o condición suspensiva, no importa la imposibilidad que puede afectar al objeto en el momento de contratar, sino que lo relevante es que sea posible al tiempo del cumplimiento del plazo o condición. El contrato que, inicialmente, era imperfecto, es convalidado por el hecho sobreviniente que hace posible el objeto previsto por las partes.

5. La licitud del objeto

El objeto debe ser lícito y conforme al orden público. Todo objeto contrario a la ley anula la obligación. La ilicitud puede nacer de que el hecho previsto esté prohibido o que se trate de un bien que, por un motivo especial, la ley también lo prohíbe. Ejemplos de ellos son, respectivamente, el contrato celebrado entre padres e hijo menor de edad, prohibido por el artículo 689, y la constitución de una hipoteca sobre una cosa mueble (art. 2205).

Por otra parte, los artículos 279 y 1004 establecen que el hecho objeto del contrato no puede ser contrario al orden público. El artículo 12 reitera la idea cuando dispone que ***las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público***. Ejemplo de ello son los contratos celebrados en el exterior para eludir prohibiciones impuestas en nuestro ordenamiento legal.

6. La dignidad de la persona humana

Fiel al postulado del necesario resguardo y protección de la persona humana, y en una de las novedades más trascendentes que ha traído el Código Civil y Comercial, los artículos 279 y 1004 disponen que el hecho, objeto del contrato, no puede ser contrario a la dignidad humana.

Es claro que estamos ante un contrato de objeto ilícito, pero es bueno que se le haya dado autonomía conceptual, para poner más en evidencia la centralidad que debe ocupar el hombre en la sociedad contemporánea. Quedan así prohibidos todos los contratos que tengan como objeto derechos personalísimos, tales como la vida, la integridad física, la honra, etc., o que afecten su dignidad, como sería el contrato que obligue a prestar servicios denigrantes.

7. Concepto de moral y buenas costumbres

Ya hemos señalado que objeto de los contratos no debe ser un hecho que sea contrario a la moral y a las buenas costumbres. En verdad, este requisito también podría considerarse comprendido en el recaudo de la licitud del objeto, pues no cabe duda de que los contratos inmorales son ilícitos. Sin embargo, la extraordinaria importancia de este supuesto de nulidad hace aconsejable tratarlo por separado.

Todo el orden jurídico está dominado por la idea moral, puesto que el derecho no es, en definitiva, otra cosa que un *orden justo*. Es natural, por lo tanto, que también los actos jurídicos deban ajustarse a principios éticos. No se concebiría, en efecto, que el Estado volcase el peso de su *imperium* en apoyo de una pretensión inmoral.

Ahora bien: ¿cuándo debe reputarse que un acto es contrario a las buenas costumbres?

Según una opinión muy generalizada, las buenas costumbres a que la ley se refiere, son la *moral media* de un pueblo en un momento dado. En efecto, si bien es preciso reconocer que el criterio sociológico tiene proclividad a un exceso de tolerancia y a que los jueces depongan su papel de guardianes de la conducta moral de los individuos en la sociedad, también debe admitirse que el extremo contrario es malo. El juez no debe aplicar un criterio muy riguroso para juzgar la moralidad de un acto; solo cuando éste choca abiertamente contra el concepto general de moral y bien común debe declararse su invalidez. De lo contrario se entraría en un terreno resbaladizo y peligroso. El juez, en verdad, debe apreciar el caso con el criterio de un hombre honorable y prudente.

Es importante señalar que si lo que resulta contrario a la moral es el hecho que configura el objeto, el contrato es nulo porque está afectado uno de sus elementos esenciales; pero si lo inmoral es una cláusula accesoria, el juez puede mantener la validez del acto y declarar sin efecto la cláusula inmoral. Esta última solución es la que ha puesto en práctica nuestra jurisprudencia para reducir los intereses usurarios, para declarar ineficaz la cláusula resolutoria en las ventas de inmuebles por mensualidades cuando se ha satisfecho una parte sustancial del precio, para anular las cláusulas abusivas pactadas en los denominados contratos de adhesión, etc. Incluso, en ciertos casos, ha sido el legislador el que ha consagrado la ineficacia de ciertas cláusulas, sin afectar el resto del contrato. Tal es lo que ocurre con la cláusula que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, la cual se tiene por no escrita (art. 37, inc. c), ley 24.240).

Ahora bien, como ya se dijo, **si lo que resulta contrario a la moral es el hecho que configura el objeto, el contrato es nulo**. En este sentido, los jueces han juzgado inmoral a aquellos contratos que se oponen a la libertad de acciones o de conciencia, como lo son la obligación de habitar en un lugar determinado o sujetar la elección de domicilio a la voluntad de un tercero, la de mudar o no mudar de religión, la de casarse con determinada persona, o con aprobación de un tercero, o en cierto tiempo o en cierto lugar, o no casarse, la de vivir célibe perpetua o temporalmente, etc. Otros ejemplos son los contratos de trabajo vinculados con casas de tolerancia, los convenios que implican el pago del comercio sexual, el pago de la influencia política, etc.

En otros casos, ha sido el legislador que, inspirado en razones morales, ha establecido la nulidad de ciertos contratos. Así, por ejemplo, la nulidad que, como regla, pesa sobre los contratos que versan sobre una herencia futura (art. 1010, párr. 1º); o que persigan la disposición de parte del propio cuerpo (art. 56); o que instalen prostíbulos en un inmueble (art. 2047, inc. a)).

8. ¿Solo las prestaciones susceptibles de valoración económica pueden ser objeto de los contratos?

El artículo 1003 establece que el objeto del contrato debe ser *susceptible de valoración económica*.

La educación de los hijos, el sostenimiento de hospitales, escuelas, bibliotecas, etc., constituyen el fundamento de contratos frecuentísimos. No se exige, pues, que el acreedor tenga un *interés* pecuniario. Pero ello no quiere decir que las obligaciones puedan ser ajenas al patrimonio. La cuestión se aclara distinguiendo entre la *prestación* u *objeto* de la obligación, que siempre debe tener contenido patrimonial, y el *interés protegido*, que puede ser humano, cultural, científico, moral; basta que sea digno de tutela. Pero la prestación en sí misma debe ser siempre susceptible de valoración económica porque de lo contrario no sería posible la ejecución del patrimonio del deudor.

La idea ha sido expresada con claridad en el Código Civil y Comercial cuando establece que el objeto debe ser *susceptible de valoración económica y corresponder aun interés de las partes, aun cuando éste no sea patrimonial* (art. 1003).

9. La energía y las fuerzas naturales susceptibles de apropiación

Durante largo tiempo se discutió en la doctrina si las energías (electricidad, energía atómica, etc.), eran o no cosas. Esta discusión quedó terminada cuando la ley 17.711, del año 1968, agregó al artículo 2311 del Código Civil de Vélez un párrafo que

establecía: *Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación*. El Código Civil y Comercial ha recogido la misma idea en el artículo 16: *Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre*.

No cabe duda, por tanto, que tales energías pueden ser objeto de los contratos, lo que es natural, porque ellas tienen un contenido económico que las asimila a las cosas. Entre el gas (indiscutiblemente una cosa, porque es un cuerpo gaseoso) y la electricidad que se consume en una casa, es difícil establecer diferencias conceptuales desde el punto de vista jurídico: ambos sirven de energía calórica o lumínica, ambos se consumen con el uso, pueden medirse, tienen un valor económico, son susceptibles de apropiación, son usadas por el hombre. No es lógico, por tanto, aplicarles reglas jurídicas distintas.

CAPÍTULO VIII - CAUSA

10. Diversos significados de la palabra *causa*

La palabra *causa* tiene en el derecho dos acepciones diferentes: a) designa, a veces, la *fuerza* de las obligaciones, o sea, los presupuestos de hecho de los cuales derivan las obligaciones legales: contratos, hechos ilícitos, etc. (en este sentido, art. 726); b) otras veces, en cambio, es empleada en el sentido de *causa final*; significa el *fin* que las partes se propusieron al contratar (en este sentido, art. 281).

Es este segundo significado el que ahora nos interesa. Y es precisamente respecto de él que se ha trabado un interesantísimo debate doctrinario. Se ha discutido si la causa debe o no ser considerada como un elemento esencial del acto jurídico; se ha discutido, incluso, la propiedad de la palabra causa; y, lo que es más grave, existen profundas divergencias respecto del significado cabal de esta institución. ¿Qué es la causa? Es necesario confesar que los esfuerzos de los juristas por precisar con claridad el concepto no han sido muy fructíferos. Subsisten aún hoy, después de una abundantísima literatura sobre el tema, importantes divergencias, aunque nuestra legislación, como se verá más adelante, toma una clara posición conceptual.

11. La cuestión en nuestro derecho

La cuestión se simplifica en la actualidad, desde que la causa, como finalidad, ha sido expresamente prevista por el Código Civil y Comercial al tratar el acto jurídico en la sección 2ª, capítulo 5, título IV, del Libro Primero. Además, cuando se refiere a la causa del contrato (capítulo 6, título II, Libro III), expresamente se remite a aquellas normas en el artículo 1012.

12. La causa en el Código Civil y Comercial

Dispone el artículo 281 que *la causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes*.

Como se puede apreciar, el Código ha adherido a la concepción de la causa que hemos denominado dualista. En efecto, por un lado afirma que la causa es el fin inmediato, determinante de la voluntad de las partes y que está autorizado por el ordenamiento jurídico. Es, entonces, la razón directa y concreta de la celebración del acto, cuya evidencia es tan nítida que la contraparte no puede ignorarla. Pero a esta función económica y social que el negocio es idóneo a realizar por sí, es necesario añadir un sentido moralizador. Y ello se logra afirmando que integran la causa los motivos o fines mediatos y subjetivos, que hayan sido exteriorizados siempre que sean lícitos y estén incorporados al contrato de manera expresa, o implícita si son esenciales para ambas partes.

Si bien, como ya dijimos, el artículo 281 se refiere a los actos jurídicos en general,

ello es aplicable a los contratos por dos motivos. El primero, porque todo contrato es un acto jurídico; el segundo, porque el artículo 1012 dispone expresamente que *se aplican a la causa de los contratos las disposiciones de la Sección 2ª, Capítulo 5, Título IV, Libro Primero de este Código*, en donde justamente está el referido artículo 281.

13. Presunción de la existencia de causa

Establece el artículo 282, en su primera parte, que *aunque la causa no esté expresada en el acto se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario*.

La solución de nuestra ley es perfectamente lógica; los hombres no se obligan ni actúan en el campo del derecho porque sí, sin motivo o causa valedera, porque ello sería irrazonable. Además, una razón de buena fe y de seguridad en los negocios obligaa reconocer efectos jurídicos a las declaraciones de voluntad, mientras no se pruebe que adolecen de algún defecto legal que las invalide. Por ello se presume la existenciay licitud de la causa. Pero, desde luego, queda a salvo el derecho del deudor a demostrar que no es así.

Nuestra ley exige que la causa exista no solo durante la formación del contrato y cuando se lo celebra; ordena también que subsista durante su ejecución (art. 1013). Como se ve, se trata de un elemento vital del contrato, que debe subsistir durante todo el período contractual y hasta el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Es que la finalidad perseguida puede desaparecer durante la vida del contrato, frustrándose así lo pretendido por las partes. A esta cuestión nos hemos de referir más adelante (nro. 173).

14. Falta de causa y falsa causa

Importando la causa un requisito esencial de los actos jurídicos, la falta de ella implica, como regla, la nulidad del acto. Sin embargo, nuestro Código prevé dos opciones más que pueden darse: la adecuación del contrato o su extinción (art. 1013). La adecuación del contrato resulta una solución lógica: en la medida en que se pueda salvar el contrato, habrá que procurar conservarlo (art. 1066). Así ocurriría ante una modificación de las condiciones previstas al momento de contratar que frustren parcialmente la finalidad perseguida por los contratantes; la adecuación de las prestaciones es la razonable solución. En cuanto a la hipótesis de extinción del contrato, ella apunta a la causa que desaparece durante la vida del contrato. En este caso, no podrá hablarse de nulidad, toda vez que el vicio no afecta el momento inicial de la celebración del contrato, sino que él se da en el transcurso contractual. Y en este supuesto, la falta de causa acarrearía la extinción del contrato.

En teoría se ha pretendido distinguir la falta de causa de la falsa causa. Pero es evidente que ambas hipótesis se confunden. Cuando una persona contrae una obligación en virtud de una determinada causa y luego resulta que esta no existe, falta la causa; y éste es, precisamente, un caso típico de falsa causa. No se puede concebir que falte la causa, sin vincular ese hecho con un error, que hizo creer en la existencia de algo que en verdad no existía.

Sin embargo, puede ocurrir que la causa expresada en el acto jurídico sea falsa; ello no obsta a que el acto sea válido si se funda en otra causa verdadera (art. 282). Lo que interesa, en definitiva, es la causa real, no la aparente. Esta cuestión se vincula con el problema de la simulación.

15. Causa ilícita

Establecía el artículo 502 del Código Civil de Vélez que la causa era ilícita cuando fuera contraria a las leyes o al orden público. Si bien la norma no se refería expresamente a la moral y a las buenas costumbres, se consideraba pacíficamente que los contratos que fueran contrarios a ellas quedaban incluidos en la ilicitud.

El artículo 1014, en su inciso a), ha consagrado la nulidad del contrato cuando su causa sea contraria a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. La causa, en este caso, debe ser entendida como el fin inmediato y determinante que han tenido en mira las partes al contratar, la razón directa y concreta de la celebración del acto.

¿Quedan fuera de la norma los fines mediatos, subjetivos, cuando integran (expresa o implícitamente) la declaración? No, pues la primera parte del inciso b) de este artículo 1014 también dispone la nulidad del contrato cuando *ambas partes lo han concluido por un motivo ilícito o inmoral común*.

Ahora bien, ¿qué sucede si solo una de las partes ha obrado por un motivo ilícito o inmoral? Ella no tendrá derecho a invocar el contrato frente a la otra, pero esta podrá reclamar lo que ha dado, sin obligación de cumplir lo que ha ofrecido (art. 1014, inc. b), 2ª parte). Se trata de una solución lógica: por un lado, quien ha obrado lícitamente no se ve afectado; por el otro, quien lo hizo de manera ilícita no puede obtener provecho alguno de su acto.

CAPÍTULO IX - CONSENTIMIENTO CONTRACTUAL

16. Cuestiones preliminares

El consentimiento contractual es una declaración de voluntad, y que existen diferentes maneras de manifestar esa voluntad.

En efecto, la voluntad puede manifestarse de manera expresa o tácita; es expresa cuando se exterioriza de manera oral, o por escrito, o por signos inequívocos, o por la ejecución de un hecho material (art. 262); es tácita cuando resulta de actos que permitan conocer la voluntad con certidumbre, y siempre que la ley o la convención no exijan una manifestación expresa (art. 264). Incluso, en limitados casos, el silencio puede importar una manifestación de la voluntad. Ello ocurre cuando se opone el silencio a un acto o una interrogación y existe un deber de expedirse que resulta de la ley, de la voluntad de

las partes, de los usos y prácticas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes (art. 263).

Estas diferentes maneras de manifestar la voluntad son, en verdad, diversas formas que la ley considera a tales efectos.

CAPÍTULO X - PRUEBA

17. Concepto

La prueba no constituye un elemento de los contratos. Sin embargo, se encuentra tan estrechamente vinculada con la forma. Se trata, claro está, de conceptos distintos. La forma hace a la manifestación de voluntad, es un requisito de la formación del contrato. La prueba, en cambio, se vincula con los medios de demostrar la existencia del contrato, cualquiera que haya sido su forma. La vinculación tan estrecha entre ambas deriva sobre todo de la circunstancia de que las formas en el derecho moderno están principalmente instituidas con el objeto de facilitar la prueba, sea a las partes, sea a terceros.

Hay dos sistemas probatorios: el de la prueba legal y el de la libre convicción. Según el primero, solo puede admitirse como prueba suficiente la que indica la ley; de acuerdo con el segundo, el juez puede admitir todo género de pruebas y tendrá como suficientes aquellas que según su ciencia y conciencia, sean suficientes para tener por acreditados los hechos. En el derecho moderno, el sistema imperante es el de la libre convicción; las limitaciones al libre arbitrio judicial para la apreciación de la prueba tienen carácter excepcional. Sin embargo, debe decirse que las excepciones son importantes y numerosas. Tal es, por ejemplo, la formalidad exigida por el artículo 1552; la ley no admite otra prueba que la escritura pública.

18. Método del Código Civil y Comercial

El Código Civil y Comercial trata la prueba en el capítulo 8, del título II, del Libro Tercero, titulado "Prueba" (arts. 1019 y 1020); independientemente de ello, legisla sobre instrumentos públicos, privados y particulares —que también son medios probatorios— en el capítulo 5, del título IV, del Libro Primero, referido a los actos jurídicos.

19. Los medios de prueba

Según el artículo 1019, los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica, y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio especial.

La regla es clara: los contratos pueden probarse por todos los medios aptos, a menos que una ley disponga un medio especial. Así ocurre con la escritura pública que es el único medio que existe para poder probar una donación de un inmueble, de muebles registrables o de prestaciones periódicas o vitalicias (art. 1552).

En general, los contratos pueden probarse:

a) Por instrumentos públicos

Es decir, por aquellos instrumentos que gozan de autenticidad, porque ha actuado el oficial público en los límites de sus atribuciones y de su competencia territorial (excepto que el lugar sea generalmente tenido como comprendido en ella) y porque está firmado por ese oficial público, las partes y, en su caso, sus representantes (art. 290).

b) Por instrumentos particulares firmados o no firmados

Los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados; ellos deben estar firmados por las partes contratantes. Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados; son instrumentos particulares no firmados los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y, cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información (art. 287). Un ejemplo, entre tantos, de instrumento particular no firmado es el de las entradas de espectáculos públicos.

La autenticidad de la firma puede probarse por cualquier medio. Si el contratante no sabe o no puede firmar, el contrato puede celebrarse dejando constancia de la impresión digital o recurriendo a dos testigos que deben suscribir el instrumento (art. 313). Cuando el documento ha sido signado con la impresión digital, vale como principio de prueba por escrito y puede ser impugnado en su contenido (art. 314).

c) Por los libros y demás registros contables

Las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios deben llevar determinados libros y registros contables.

Quedan eximidos de esta obligación los profesionales liberales y quienes desarrollan actividades agropecuarias y conexas, no ejecutadas u organizadas en forma de empresa (art. 320). Son registros indispensables, entre otros, los libros diario y de inventario y balances (art. 322).

d) Por la correspondencia, cualquiera que sea el medio empleado para crearla o transmitirla

Puede presentarse como prueba por el destinatario, pero la que es confidencial no puede ser utilizada sin consentimiento del remitente. Los terceros, en cambio, no pueden valerse de la correspondencia sin el asentimiento del destinatario, y del remitente si es confidencial (art. 318).

Finalmente, debe señalarse que la regla de que los contratos pueden probarse por todos los medios aptos, a menos que una ley disponga un medio especial, tiene una limitación: *los contratos que sea de uso instrumentar no pueden ser probados exclusivamente por testigos* (art. 1019). Cuando se hace referencia a los contratos que sea de uso instrumentar se está afirmando que hay contratos que normalmente, por los usos y costumbres, se suelen celebrar mediante instrumentos públicos o privados, o por instrumentos particulares no firmados, que incluyen impresos, registros visuales o auditivos, registros de la palabra y de información, abarcándose así a los documentos informáticos.

20. Prueba de los contratos formales

Establece el artículo 1020 que los contratos en los cuales la formalidad es requerida a los fines probatorios, pueden ser probados por otros medios, inclusive por testigos, si hay imposibilidad de obtener la prueba de haber sido cumplida la formalidad o si existe principio de prueba instrumental, o comienzo de ejecución.

Con otras palabras, si la formalidad establecida por la ley es meramente requerida a los fines probatorios, el contrato puede ser probado por otros medios.

21. Principio de prueba instrumental

Se considera principio de prueba instrumental cualquier instrumento que emane de la otra parte, de su causante o de parte interesada en el asunto, que haga verosímil la existencia del contrato (art. 1020, párr. 2º). La prueba instrumental comprende a todo instrumento público y privado, a todo documento y a cualquier instrumento particular no firmado, con lo que se incluyen los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas hechos y, cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información (art. 287). Quedan incluidos, por tanto, los documentos digitales y los correos electrónicos, entre otros.

Para que haya principio de prueba instrumental es, por tanto, necesario: a) que el instrumento emane de la otra parte, su causante, o parte interesada; no es necesario que esté firmado por él; b) que haga verosímil el contrato. Basta con que confluyan estos requisitos para hacer viable cualquier clase de prueba, inclusive testigos.

Sin embargo, debe quedar claro que el principio de prueba instrumental no es un medio probatorio de los contratos, por cuanto de él no resulta la verdad, sino únicamente la verosimilitud del hecho alegado. Es decir, es un comienzo de prueba que abre el acceso a todos los medios de prueba existentes, incluso la prueba de testigos (conf. CNCom., Sala C, 13/10/16, "T., H. L. y otros c/Z., J. M. y otros s/ordinario", E.D. t. 270, p. 535).

CAPÍTULO XI - EFECTOS DEL CONTRATO

22. Planteo general

El tema de los efectos del contrato abarca dos cuestiones diferentes. Por un lado, lo que podemos denominar las consecuencias propias del contrato; por el otro, las repercusiones de ese contrato en las personas.

Las consecuencias propias del contrato apuntan a dos temas centrales: la autonomía

de la voluntad y la fuerza obligatoria del contrato. Si bien gozamos de la libertad de contratar o no contratar, de elegir con quién contratar, y de configurar el contenido del contrato, es claro que una vez que lo hemos celebrado, quedamos obligados en sus términos, respetando, desde luego, los límites que la propia legislación puede imponer.

En cuanto a la repercusión del contrato, hay que poner de relieve que los efectos generados por el contrato y, en general, por todo acto jurídico, recaen sobre las partes intervinientes y sobre sus sucesores; incluso, se ha consagrado, como regla, que los contratos no producen efectos respecto de terceros. Sin embargo, hemos de ver que esta regla tiene limitaciones, pues los contratos pueden afectar a los terceros o repercutir en los intereses de los acreedores de las partes contratantes.

§ 1.— Fuerza obligatoria del contrato y autonomía de la voluntad

23. La fuerza obligatoria del contrato

Los contratos deben cumplirse, pero ¿por qué razón?

La fuerza obligatoria del contrato se ha fundado con diversos argumentos. En el derecho canónico se invocó la idea del orden moral, basada en que, quien no cumplía con la palabra empeñada, incurría en una mentira que violaba directamente uno de los diez mandamientos; existe, por tanto, una regla ética de conducta que impone el deber de conciencia de respetar la palabra empeñada. Más tarde, la Escuela de Derecho Natural hizo hincapié en la idea del pacto social, por el cual los contratos obligan a sus celebrantes en tanto existiría un convenio anterior y tácito, otorgado contemporáneamente a la constitución de la vida social, y por el cual los hombres se habrían obligado a ser fieles a sus promesas.

Para la Escuela Filosófica del Derecho el fundamento de la obligatoriedad de los contratos se encuentra en el hecho de que el hombre dicta su propia ley. Es el mismo hombre quien voluntariamente se somete a lo convenido; de alguna manera, se autoacciona. En esta línea, Francesco MESSINEO (*Doctrina general del contrato*, Ejea, Buenos Aires, 1952, t. I, p. 52) ha afirmado que la obligatoriedad del contrato surge del hecho de que las partes han aceptado libremente su contenido, suscribiendo también la limitación de las respectivas voluntades que de él derivan, y surge además de la confianza suscitada por cada contratante en que el otro cumplirá con la promesa que ha hecho.

Las ideas expuestas procuran dar sustento a algo que resulta no solo evidente, sino fundamental: como principio general, el contrato celebrado debe ser cumplido. Y esta es también la idea del Código Civil y Comercial cuando dispone que *todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes* (art. 959).

El Código Civil de Vélez, con otras palabras, recogía la misma idea, al establecer que las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma (art. 1197, Cód. Civil). Si bien hay una idea de asimilar los efectos del contrato a los efectos de la ley, la asimilación no era plena (como sí ocurre con su antecedente, el art. 1134 del Código Napoleón, que lisa y llanamente establece que el contrato es ley para las partes) porque ese someterse al contrato "como" a la ley misma, implica que existe un espacio en el que se introduce la regla moral, regla moral esta que —por un lado— obliga a respetar y cumplir la palabra empeñada, pero —por el otro— impide que puedan consagrarse situaciones de aprovechamiento —subjetivo (v.gr., la lesión) u objetivo (ej., teoría de la imprevisión)—de un contratante sobre otro.

Por último, cabe añadir que más allá de que la fuerza obligatoria de los contratos, afirmada en el artículo 959, encuentre su fundamento en el respeto de la voluntad de los contratantes, como hemos visto, también reconoce la importancia de las necesidades del tráfico. El artículo 959 dice: "Efecto vinculante. Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley lo prevé." Es que los contratos constituyen el principal medio del que se valen los hombres para tejer entre ellos la urdimbre de sus relaciones jurídicas. Son, por consiguiente, un instrumento esencial para la vida económica y para la promoción de la riqueza; por todo ello es indispensable reconocerles fuerza jurídica. Media en la cuestión un interés de orden público.

24. La autonomía de la voluntad

Ha señalado Benjamín MOISÁ (*La autonomía de la voluntad y la predisposición contractual*, nro. 13, Zavallía, Buenos Aires, 2005) que la autonomía de la voluntad es la cualidad de la voluntad en cuya virtud el hombre tiene la facultad de autodeterminarse y autorresponsabilizarse, conforme a los dictados de su conciencia, sin más límites que las idénticas y concurrentes facultades de otros hombres.

La autonomía de la voluntad se vincula estrechamente con la fuerza obligatoria del contrato, en tanto lo que se procura es que el contrato libremente pactado (esto es, que haya sido celebrado con pleno discernimiento, intención y libertad, art. 260, Cód. Civ. y Com.) obligue, sin más, a las partes. En otras palabras, el mero consentimiento contractual, prescindiendo de toda otra formalidad, obliga a los contrayentes, pues si bien las personas son libres de obligarse o no, una vez que se han obligado deben cumplir la obligación asumida o responder por su incumplimiento.

Durante el siglo XIX, el individualismo reinante exaltó la idea de la autonomía de la voluntad, consagrada en la fórmula del *laissez faire, laissez passer*. Ya la Declaración de los Derechos del Hombre, en el año 1789, disponía que todo aquello que no fuese objeto de prohibición estaba permitido (art. 5º). Había que dejar a los contratantes que celebraran sus contratos libremente, pues ellos mismos serían los mejores defensores de sus propios intereses y así se lograría un orden económico de equilibrio y crecimiento.

El Estado debía, entonces, limitarse a asegurar ese libre juego de la autonomía de la voluntad, en dos aspectos centrales de la libertad humana en el mundo de los contratos: las denominadas libertad de contratar y libertad contractual. La libertad de contratar apunta, por una parte, a la libertad que toda persona tiene de contratar o de no contratar y, por otra parte, a la libertad de elegir con quién contratar. La libertad contractual – también llamada libertad de configuración –, en cambio, se refiere a la libertad para fijar el contenido del contrato.

En este marco de amplia libertad, las únicas restricciones a la contratación venían de la mano de los principios de orden público y de las buenas costumbres, y en la limitación que impone la necesidad de que la contratación sea lícita y no afecte derechos de terceros. Era inadmisibles que la ley se inmiscuyera en la vida de los contratos y se proclamaba que los jueces carecían de toda facultad para morigerar o atenuar los efectos del contrato.

Sin embargo, ya entrado en el siglo XXI, resulta indudable que los ideales de libertad e igualdad pregonados por la Revolución Francesa se han demostrado cuestionables en la práctica: no todos somos en las mismas condiciones ni todos somos libres para contratar; menos aún para discutir cada cláusula. ¿Existe tal libertad, acaso, cuando se celebra un contrato de apertura de cuenta corriente bancaria, en el que el peticionante solo tiene la posibilidad de firmar el contrato preimpreso que le presenta el banco o quedarse sin la ansiada cuenta corriente?

Es necesario dejar a un lado la utopía del contrato ideal para hacer jugar el contrato real, el que atiende a las diferencias. Hoy, a los históricos límites de la autonomía de la voluntad conformados por los principios de orden público y de las buenas costumbres, la necesaria licitud de la contratación y la no afectación de terceros, deben añadirse las normas imperativas, la regla moral, la buena fe contractual, el ejercicio regular de los derechos y la equidad (que no es sinónimo de equivalencia económica) de las prestaciones.

Por otra parte, es visible que existen contratos en donde las libertades configurativas de la autonomía de la voluntad tienden a desaparecer. Así, en los contratos de adhesión, la libertad contractual queda absolutamente conmovida, en tanto el contenido del contrato es configurado exclusivamente por el proponente, quedándole al adherente solo el derecho (la libertad) de contratar o no contratar. En otras ocasiones, la propia libertad de contratar parece desaparecer –es el caso de los denominados "contratos forzosos"– en el que el sujeto está obligado a contratar, como ocurre con el contrato de seguro automotor obligatorio previsto en el artículo 68 de la ley 24.449.

Sin caer en excesos o abusos intervencionistas, que se han mostrado no solo inútiles sino –peor aún– contraproducentes (el más claro ejemplo de ello fueron las leyes de

prórroga de las locaciones inmobiliarias de mediados del siglo XX), parece claro que existe una necesidad de apuntalar la idea del contrato justo. Es por ello que se reconocen ciertos límites a la fuerza obligatoria de los contratos.

25. Atenuación a la fuerza obligatoria de los contratos

Hemos dicho que la fuerza obligatoria de los contratos no se funda solo en el respeto por la libertad y la voluntad individual, sino también en las exigencias del tráfico social. El interés social vitaliza los contratos, fecunda las manifestaciones de voluntad y, al propio tiempo, señala límites a la autonomía de la voluntad. Por consiguiente, los contratos carecerán de fuerza obligatoria:

a) Si son contrarios a las leyes de carácter imperativo o indisponible. El Código Civil y Comercial ha profundizado esta prohibición al disponer que *el acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal, que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley*. Y añade que *en ese caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir* (art. 12). Con otras palabras, si las partes –amparándose en una norma permitida– procuran un resultado similar en su sustancia al que prohíbe una norma imperativa, el contrato quedará sometido a las reglas de la norma imperativa que se quiso eludir.

b) Si procuran dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público (art. 12).

c) Si son contrarios a la moral (art. 1004). De esta misma idea moral han surgido las siguientes limitaciones: 1) Carecen de fuerza obligatoria las cláusulas penales excesivas (art. 794). 2) Pueden modificarse las obligaciones contractuales cuando una alteración imprevisible y extraordinaria ha modificado sustancialmente los presupuestos económicos del contrato (teoría de la imprevisión, art. 1091). 3) Puede anularse o modificarse el contrato celebrado con vicio de lesión (art. 332), esto es, cuando una de las partes se encuentra bajo la presión de apremiantes necesidades, que son conocidas y explotadas por la otra, y que la llevan a celebrar un contrato gravoso o inconveniente para su patrimonio.

Asimismo, no tendrán validez aquellas cláusulas contractuales que importen un abuso del derecho. El artículo 10 dispone que *la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres*. Y se añade algo esencial: *el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización*. Por lo tanto, si se trata de una cláusula contractual abusiva, el juez debe dejarla sin efecto y, claro está, debe ordenar reparar el daño causado.

El artículo 11 del Código Civil y Comercial ha recogido otro límite a la fuerza obligatoria del contrato: el llamado abuso de posición dominante. Allí se dispone que lo establecido en materia de buena fe y abuso del derecho es aplicable *cuando se abuse de una posición dominante en el mercado, sin perjuicio de las disposiciones específicas contempladas en leyes especiales*. Para establecer el campo de aplicación de esta norma, habrá que i) delimitar cuál es el mercado relevante, considerando tanto el producto como el área geográfica de que se trate; ii) determinar si efectivamente hay una posición dominante en el mercado; iii) verificar si ha habido una práctica abusiva por parte de quien ocupa la posición de dominio, y iv) comprobar si existe un perjuicio para el interés económico general. Un contrato celebrado en tales condiciones debe ser anulado.

Una novedad que trae el Código Civil y Comercial es el reconocimiento de los derechos de incidencia colectiva (ya consagrados en el art. 43 de la CN) junto con los derechos individuales. Dispone el artículo 14 que *la ley no ampara el ejercicio abusivo*

de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. Los derechos de incidencia colectiva (que justamente incluyen el derecho al ambiente sano) consisten en derechos pertenecientes a un grupo indeterminado de personas y concernientes a intereses indivisibles.

Finalmente, debe señalarse que, como regla, los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos. Sin embargo, se prevén dos excepciones. La primera, que una de las partes lo pida, y siempre que lo autorice la ley; la segunda, actuando de oficio, si la cláusula afecta, de modo manifiesto, el orden público (art. 960). Hemos de señalar, sin embargo, que las dificultades que existen para definir el orden público, cuyo concepto se ha mantenido en estado brumoso, al decir de Manuel ARÁUZ CASTEX (*Derecho civil. Parte general*, Empresa Técnico Jurídica, Buenos Aires, 1965 t. I, nro. 306.), hacen prever que la intervención judicial de oficio no será acotada.

26. La buena fe en los contratos

No es posible cerrar el desarrollo de la fuerza obligatoria de los contratos sin referirnos a su principio cardinal: *los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe* (art. 961). Añade esta norma que los contratos *obligan no sólo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor*.

Disponía el art. 1198 del Código Civil, luego de la reforma de la ley 17.711, que los contratos debían celebrarse, interpretarse y ejecutarse de acuerdo con lo que verosíblemente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. Si bien este concepto no ha sido incluido de manera expresa en el Código Civil y Comercial, resulta indudable su aplicación porque ese obrar cuidadoso es una característica constitutiva de la buena fe.

Detengámonos brevemente en el concepto de buena fe.

Siguiendo la terminología usual, debe distinguirse entre la buena fe-creencia y la buena fe-lealtad. La primera consiste en un estado de ánimo que confía en la apariencia de un título. Así, por ejemplo, son válidos los actos de administración y de disposición a título oneroso de los bienes de la sucesión celebrados por el heredero aparente (quien, en verdad, no es heredero) respecto de los terceros a quienes ha transmitido el derecho.

La buena fe-lealtad es el deber de obrar en las relaciones contractuales con probidad, *como lo haría una persona honorable y correcta*, obrando con cuidado y previsión. Esta buena fe obliga a ser claro en las ofertas y tratativas contractuales, de modo de no inducir a error a la otra parte; a interpretar el contrato honorablemente; a abstenerse de todo acto que dificulte el cumplimiento por la otra parte o que implique terminar intempestivamente las relaciones contractuales; etcétera.

CAPÍTULO XIII - EFECTOS PARTICULARES

§ 1.— Excepción de incumplimiento

27. Concepto y antecedentes históricos

En los contratos de los cuales nacen obligaciones simultáneas a cargo de ambas partes, una de ellas no puede reclamar a la otra el cumplimiento si no hubiera cumplido sus propias obligaciones u ofreciere cumplirlas.

En otras palabras, si una de las partes de un contrato sinalagmático, es decir, con contraprestaciones recíprocas, exige la ejecución de su crédito sin cumplimentar u ofrecer cumplir su propia deuda, la otra parte puede rehusarse oponiendo la denominada excepción de incumplimiento contractual.

En virtud de esta defensa, un contratante tiene derecho a abstenerse de cumplir su prestación si no adviene el cumplimiento simultáneo de la prestación correlativa.

La excepción de incumplimiento contractual (también llamada *exceptio non*

adimpleti contractus o excepción de contrato no cumplido) es, entonces, la facultad que tiene un contratante de diferir legítimamente el cumplimiento de su propia obligación, hasta tanto la otra no cumpla la suya u ofrezca cumplirla simultáneamente, a menos que esta última sea a plazo.

La excepción de incumplimiento contractual ha sido consagrada por nuestro Código en la primera parte del artículo 1031 que expresamente dispone que *en los contratos bilaterales, cuando las partes deben cumplir simultáneamente, una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación, hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir*.

Se trata de una *medida de autodefensa privada*, con carácter coercitivo, tendiente a salvaguardar el equilibrio contractual, y que permite no cumplir porque el otro no ha cumplido.

La excepción de incumplimiento contractual constituye una de las instituciones más tradicionales en el derecho de los contratos. Se la conoció ya en el derecho romano, en el que se distinguía entre la excepción de incumplimiento total (*exceptio non adimpleti contractus*) y la de incumplimiento parcial o de cumplimiento defectuoso (*exceptio non rite adimpleti contractus*). La acogió el derecho moderno, para el cual el principio de que nadie puede demandar el incumplimiento de un contrato sin haberlo cumplido por su parte, se funda en una razón de moral y buena fe. Hoy es un principio admitido universalmente (Cód. Civil italiano, art. 1460; alemán, art. 320; de las Obligaciones suizo, art. 82; brasileño, art. 476; paraguayo, art. 719; peruano, art. 1426; ecuatoriano, art. 1568; venezolano, art. 1168).

28. Fundamento

Regla tan prestigiosa y tan universalmente admitida debe tener sólidos fundamentos. Y, efectivamente, así es. Los contratos que originan obligaciones a cargo de ambas partes importan un trueque, un cambio, una reciprocidad. No se puede pretender recibir si no se da. Media en esto una cuestión de buena fe y de moral.

29. Retardo de la ejecución y ausencia de mora

Ya hemos dicho que la parte a quien se le reclama el cumplimiento de su obligación puede retardar su ejecución hasta que la otra cumpla con la suya. Esto significa, además, que el deudor no incurre en mora durante el tiempo de espera, pues su demora responde a un derecho legítimo.

Es cierto que el Código Civil y Comercial no contiene una norma análoga al artículo 510 del Código Civil de Vélez, según el cual uno de los obligados no incurre en morosi si el otro no cumple o no se allana a cumplir sus propias obligaciones, pero parece claro que no puede ser otra la solución, toda vez que no puede incurrir en mora quien se acoge a una facultad, la de oponer la *exceptio*, expresamente reconocida por la ley.

Podría sostenerse que si una de las partes ha sido constituida en mora, en un contrato bilateral, no puede invocar la *exceptio*, por cuanto la morosidad previa impediría alegar la mora del cocontratante. Sin embargo, pensamos que nadie puede ser constituido en mora cuando la contraparte, en los contratos bilaterales, no cumple las obligaciones que le son respectivas. Aunque la mora sea automática ella no se opera cuando aparece un factor impeditivo, cuál sería el incumplimiento del acreedor de sus propias obligaciones correlativas.

30. Condiciones de ejercicio

Para que proceda la *exceptio non adimpleti contractus* es necesario:

a) Que se trate de un contrato bilateral (art. 1031). Como esta noción de contrato bilateral es bastante confusa (y, a nuestro entender estéril, véase nro. 18), preferimos decir que debe tratarse de un contrato que origine obligaciones a cargo de ambas partes.

b) Que las obligaciones deban cumplirse simultáneamente (art. 1031), es decir, que no estén sujetas a plazo diferente; si la obligación de la contraparte tuviera un plazo no vencido, la excepción sería improcedente.

c) Que el que opone la excepción suspenda el cumplimiento de sus obligaciones, de manera total o parcial. En el derecho moderno no se distingue mayormente entre

la *exceptio non adimpleti contractus* y la *exceptio non rite adimpleti contractus*, más allá de la apuntada carga probatoria. Es que un incumplimiento parcial o un cumplimiento defectuoso de la contraparte son suficientes para hacer viable la excepción; en definitiva, no se ha cumplido íntegramente o de manera cabal con la obligación asumida.

Debemos agregar que a la contraparte, a quien se le opone la *exceptio*, le basta con ofrecer cumplir sus obligaciones, para paralizar sus efectos.

d) Que quien reclama el cumplimiento de la obligación, no ofrezca cumplir con la propia. En efecto, el que sin haber cumplido, demanda por cumplimiento, tiene dos posibilidades: o bien cumple en el momento de demandar (por ejemplo, consignando la suma adeudada a las resultas del pleito) o bien ofrece cumplir simultáneamente con la otra parte. Esta será ordinariamente la conducta a seguir por el actor, a quien no le conviene tener inmovilizada una suma de dinero durante toda la duración del pleito.

e) Que la *exceptio* haya sido hecha valer de buena fe, lo que implica que no puede oponerse la *exceptio* con base en un incumplimiento poco importante, pues importaría un ejercicio abusivo del derecho. Es el caso de los pequeños defectos o deficiencias que presenta un edificio, los cuales no autorizan al dueño de la obra a oponer la *exceptio* negándose a pagar el precio pactado; su derecho se limita a retener una cantidad suficiente para reparar dichas deficiencias. Tampoco proceda la *exceptio* cuando el excepcionante ha impedido por sus propios actos el cumplimiento del actor, o cuando se ha colocado él mismo en la imposibilidad de cumplir.

§ 3.— Pacto comisorio o cláusula resolutoria

31. Concepto; antecedentes

La cláusula resolutoria, clásicamente llamada pacto comisorio, es aquella que permite a los contratantes reclamar la resolución del contrato cuando una de ellas no ha cumplido con las obligaciones a su cargo.

En el derecho romano, el principio era que las partes solo podían reclamar el cumplimiento del contrato; solo cuando las partes pactaban la *lex commissoria* podían pedir la resolución.

Este principio, si bien con numerosas excepciones particulares (como ocurría con el contrato de compraventa), pasó al Código Civil de Vélez, según el cual cuando no hubiere pacto expreso que autorizara a una de las partes a disolver el contrato, si la otra no lo cumpliere, el contrato no podía disolverse y solo podía pedirse su cumplimiento. Tal sistema era anacrónico. Ya el derecho canónico, con el propósito de asegurar más enérgicamente el respeto por los compromisos contraídos, había autorizado a pedir la resolución en caso de incumplimiento. La utilidad de este recurso resulta evidente. La agilidad de los negocios, la fluidez del tráfico, exigen un procedimiento rápido y expeditivo. Es natural que si una de las partes no cumple, pueda la otra, o bien demandar el cumplimiento, o bien desligarse de sus obligaciones. Es antieconómico obligarla a seguir un juicio por cumplimiento, cuyo resultado será una sentencia que frecuentemente no podrá hacerse efectiva. Por ello, la legislación moderna se inclina decididamente a admitir que todo contrato, salvo estipulación contraria, contiene un pacto comisorio tácito que autoriza, en caso de incumplimiento, a solicitar la resolución del contrato (Cód. Civil francés, art. 1184; italiano, art. 1453; alemán, arts. 323 y ss.; de las Obligaciones suizo, art. 107; español, art. 1124; brasileño, art. 475; paraguayo, art. 725; peruano, art. 1428; chileno, art. 1489; mexicano, arts. 1949 y ss.; venezolano, art. 1167; japonés, art. 541). Era también el principio adoptado por nuestro Código de Comercio (art. 216), y por el mismo Código Civil después de la reforma introducida por la ley 17.711 (art. 1204).

Es el sistema que ha consagrado el Código Civil y Comercial. Frente al incumplimiento, la otra parte puede tenerlo por resuelto, en las condiciones fijadas por la ley, lo que será objeto de nuestro análisis en los números siguientes.

La solución es acertada y permite la rápida liquidación de situaciones contractuales perjudicadas por el incumplimiento de una de las partes.

32. Régimen legal

Aunque la cláusula resolutoria no hubiera sido pactada de manera expresa, existe la posibilidad de que se resuelva el contrato bilateral (art. 1087).

Para ello es necesario que se cumplan una serie de recaudos que la propia ley prevé.

Ante todo, se requiere que una de las partes haya incumplido su obligación (art. 1088, inc. a]). Pero no se trata de cualquier incumplimiento, sino de aquel que sea esencial en atención a la finalidad del contrato (art. 1084). Esta última norma dispone que *el incumplimiento se considera que es esencial cuando: i) el cumplimiento estricto de la prestación es fundamental dentro del contexto del contrato* (así, cuando se ha convenido la entrega de una cosa que, a su vez, ha sido prometida a un tercero); ii) *el cumplimiento tempestivo de la prestación es condición del mantenimiento del interés del acreedor* (es el caso de la confección del vestido de novia que necesariamente debe estar terminado para el día de la boda); iii) *el incumplimiento priva a la parte perjudicada de lo que sustancialmente tiene derecho a esperar* (como cuando se ha adquirido un juego de muebles determinado, que el vendedor pretende sustituir con otro); iv) *el incumplimiento es intencional*, y v) *el incumplimiento ha sido anunciado por una manifestación seria y definitiva del deudor al acreedor*.

¿Y si el incumplimiento fuera parcial? Incluso cuando el incumplimiento sea parcial, es posible invocar la cláusula resolutoria implícita. Lo que se necesita es que tal incumplimiento prive *sustancialmente de lo que razonablemente la parte tenía derecho a esperar en razón del contrato* (art. 1088, inc. a]). Para un mayor desarrollo de esta cuestión, nos remitimos al número 246.

Además, es necesario que el incumplidor haya incurrido en mora (art. 1088, inc. b]), la que como regla se produce por el solo transcurso del tiempo fijado (art. 886).

Finalmente, ocurrido el incumplimiento y la mora de una de las partes, el acreedor debe emplazar al deudor, bajo apercibimiento expreso de resolver total o parcialmente el contrato, a que cumpla con su obligación, en un plazo no menor de quince días, a menos que de los usos, o de la índole de la prestación, resulte la procedencia de uno menor (art. 1088, inc. c]). Desde luego, y aunque la norma no lo mencione de manera expresa, el acreedor también está facultado a exigir la reparación de los daños derivados de la demora.

Transcurrido el plazo sin que la prestación haya sido cumplida, la resolución se produce de pleno derecho al vencimiento de dicho plazo (art. 1088, inc. c]).

Con otras palabras, cuando la cláusula resolutoria no ha sido pactada expresamente, es necesario el requerimiento, es decir, se brinda al deudor una ocasión de cumplir. Vencido el plazo fijado en el requerimiento, la obligación se resuelve por el mero cumplimiento del plazo y sin necesidad de otra actividad ulterior del acreedor. Por lo tanto, si el acreedor requiere el cumplimiento, pero sin ánimo de resolver el contrato, deberá aclarar que no persigue tal resolución; de lo contrario, ella se producirá automáticamente.

El plazo concedido al deudor no debe ser menor de quince días, salvo que los usos o la índole de la prestación justifiquen un término más breve. También es admisible un plazo menor si las partes lo han pactado expresamente; juega aquí la autonomía de la voluntad.

La ley no establece ningún requisito formal para el requerimiento que, por lo tanto, podrá hacerse incluso verbalmente. Pero será siempre aconsejable hacerlo por un medio fehaciente, para evitar luego los inconvenientes de la dificultad de la prueba.

Este requerimiento no es necesario si ha vencido un plazo esencial para el cumplimiento, si la parte incumplidora ha manifestado su decisión de no cumplir, o si el cumplimiento resulta imposible. En tales casos, la resolución total o parcial del contrato se produce cuando el acreedor la declara y la comunicación es recibida por la otra parte (art. 1088, inc. c]).

Además, tampoco es exigible el requerimiento si la ley faculta a la parte a declarar unilateralmente la extinción del contrato, sin perjuicio de disposiciones especiales (art. 1089). Es lo que ocurre con la revocación del mandato (arts. 1329, inc. c], y 1331), entre otros ejemplos.

B.— PACTO COMISORIO EXPRESO O CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA

33. Régimen legal

Puede ocurrir que las partes hayan previsto expresamente en el contrato la cláusula resolutoria. No obstante que ya la ley da el derecho a resolver el contrato en caso de incumplimiento, tal estipulación no es inútil. En efecto, el artículo 1086 dispone que en caso de que ocurran incumplimientos genéricos o específicos debidamente identificados, se producirá la resolución del contrato, la cual surtirá efectos desde que la parte interesada comunique a la incumplidora, en forma fehaciente, su voluntad de resolver.

La diferencia con el pacto comisorio tácito es, pues, importante. En este último, para que pueda resolverse el contrato se necesita que el incumplimiento sea esencial (art. 1084); en cambio, si el pacto comisorio es expreso, la resolución puede requerirse ante cualquier incumplimiento genérico o específico que las partes hubiesen fijado (art. 1086). Además, si el pacto no hubiera sido previsto en el contrato, el contrato puede resolverse, pero la parte interesada en la resolución debe darle al deudor una última oportunidad de cumplir; si el pacto fuere expreso, el cumplidor se limita a comunicar al incumplidor su voluntad de resolver.

Adviértase que la ley dice que en este caso la resolución se produce —de pleno derecho— desde que se comunica al incumplidor la voluntad de resolver, y no desde el momento del incumplimiento o de la mora. La solución es lógica. La resolución no podría ser automática, pues el acreedor puede tener interés en exigir el cumplimiento.

Bien entendido que la comunicación solo tiene efecto si previamente el deudor ha quedado constituido en mora.

C.— PROBLEMAS COMUNES AL PACTO COMISORIO

34. Reparación del daño

Independientemente del derecho a la resolución del contrato, la parte que ha cumplido tiene derecho a la reparación de los daños sufridos (art. 1082), daños que deben ser aprehendidos con una noción amplia, comprensiva del daño emergente, el lucro cesante, el daño extrapatrimonial e, incluso, la pérdida de chance. También deberán reembolsarse los gastos generados por la celebración del contrato y por los tributos que lo hayan gravado (art. 1082, inc. b]).

35. Efectos

La invocación de la cláusula resolutoria provoca que el contrato quede sin efectos de manera retroactiva, y que las partes deban devolverse recíprocamente lo que hubieran recibido, o su valor, como consecuencia de él, en la medida que corresponda (art. 1080).

CAPÍTULO XV - INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO

§ 1.— ¿Qué se interpreta en un contrato?

36. Cuestiones generales

La pregunta que encabeza este párrafo recibe una respuesta clara: lo que se interpreta es la voluntad de los contratantes, al tiempo de celebrar el contrato. Pero, en verdad, con esta respuesta tampoco obtenemos una solución del problema.

En efecto, inmediatamente nos surge otro interrogante: ¿cuál es la voluntad de los contratantes?

§ 2.— Reglas de interpretación

37. Cuestiones preliminares

Las reglas de interpretación constituyen un sistema de reglas que gobiernan el contrato considerado en su totalidad. Considerar en su totalidad el contrato celebrado importa que no solo se procura interpretarlo, sino también que deben interpretarse todas las normas (convalidantes, supletorias o rectificatorias) que sean aplicables a ese contrato.

Las reglas tienen particular importancia para los jueces (o en su caso, para el árbitro) quienes tendrán la responsabilidad de resolver el conflicto planteado, conforme a ellas. Pero también, estas reglas tienen como destinatario a las mismas partes contratantes, a los terceros que puedan ser beneficiados por el contrato y a aquellos otros a los cuales el contrato les impone una obligación.

Mucho se ha discutido sobre si estas reglas deben ser usadas en un orden determinado o no. Sin perjuicio de que el artículo 1065 parece imponer un cierto orden, pensamos, siguiendo a Noemí Lidia NICOLAU ("Interpretación y elaboración de normas en materia contractual, con especial referencia al derecho argentino", en obra colectiva *Interpretación del contrato en América Latina*, Grijley - Universidad Externado - Rubinzal-Culzoni, t. I, p. 356), que lo fundamental es que se respete el orden lógico de las tareas a cumplir; es decir, primero debe darse la interpretación, escudriñando la voluntad común de las partes, y segundo, si fuere menester, procederse a la integración.

38. El principio general de la buena fe

Sin duda, el criterio rector en materia de interpretación de los contratos es el principio general de la buena fe, al que deben subordinarse todas las demás reglas interpretativas.

Puede sostenerse que el principio general de la buena fe es una norma jurídica que impone a las personas el deber de comportarse lealmente en el tráfico jurídico, ajustando el comportamiento al arquetipo de conducta social reclamada por la idea ética vigente. Importa, además, exigir a los sujetos una actitud positiva de cooperación y de despertar confianza en las propias declaraciones, manteniendo la palabra empeñada. Y como consecuencia de ello, opera como límite al ejercicio de los derechos subjetivos. Por lo tanto, el principio de la buena fe significa que el acreedor no debe pretender más que lo que es debido, conforme a la honesta inteligencia de las cláusulas contractuales y habida cuenta de la finalidad de ellas.

Asimismo, como la buena fe implica ajustarse a lo convenido en el contrato, ello incluye no solo el cumplimiento fiel de lo pactado sino también de los deberes accesorios de conducta, tales como los de información, cooperación, diligencia, seguridad y garantía, que se fundan en deberes de convivencia y solidaridad social, que van más allá de lo expresamente pactado, pero que impiden toda acción u omisión que pueda dañar al otro contratante, con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Nacional.

Este principio ha sido destacado por el Código Civil y Comercial en diferentes partes. En efecto, el Título preliminar lo recepta en su artículo 9º (*los derechos deben ser ejercidos de buena fe*) con una clara intención de que gobierne todas las relaciones jurídicas, sin excepción alguna. A su vez, el artículo 961 dispone que *los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe*, y que *obligan no sólo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor*. Finalmente, el artículo 1061 establece que *el contrato debe interpretarse conforme al principio de la buena fe*.

La idea resulta clara: se está pensando en un comportamiento leal, sincero, ético, sin reservas y confiado en la palabra empeñada, que en definitiva tiende a proteger a ambos contratantes, a quien recibe la declaración contra la posibilidad que el declarante alegue que quiso algo distinto de lo que expresó, y a este último contra la posibilidad de que aquel alegue que entendió lo manifestado en un sentido diferente de lo que es su significado propio. Reiterando palabras ya dichas, el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, los mismos efectos que normalmente ha producido en casos iguales.

En definitiva, interpretar un contrato de buena fe significa interpretarlo teniendo en cuenta que los contratantes han debido comportarse frente al otro lealmente, de manera sincera y sin reservas, descartando hacer uso de las facultades obtenidas con un innecesario rigor que pueda provocar un daño injusto a la contraparte. La interpretación de buena fe no puede agotarse en el contrato, sino que debe extenderse al tiempo anterior a su celebración, a las negociaciones previas (art. 991), y hacia el futuro, pues no solo deberá tener en cuenta lo expresamente pactado sino también las consecuencias que pueden considerarse comprendidas en lo convenido, siempre que se esté en el marco de un contratante previsor y cuidadoso.

El valor del principio general de la buena fe es tan importante que, como se verá, constituye el fundamento de una gran cantidad de reglas interpretativas.

39. La intención común

El artículo 1061 establece que *el contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las partes*.

La intención común de las partes presume la libertad contractual, es decir, la facultad que ellas tienen de determinar el contenido del contrato. Pero la norma hace algo más: pone de relieve la importancia de desentrañar esa intención común, que es más que la intención individual de cada contratante. Es importante, entonces, interpretar el contrato de acuerdo con la intención común de los contratantes, esto es, la común intención de obligarse y de adquirir derechos, y no la intención individual de cada contratante o su particular finalidad personal. La idea de una intención común es de gran valor, pues implica que la voluntad de las partes va más allá de la finalidad individual perseguida.

La idea de la intención común también ha sido recogida por los Principios Unidroit.

Así establecen que a) el contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las partes. Si esa intención no puede establecerse, el contrato se interpretará conforme al significado que le habrían dado en circunstancias similares personas razonables de la misma condición que las partes (art. 4.1); b) las declaraciones y demás actos de cada una de las partes se interpretarán conforme su intención, siempre que la otra haya conocido o no la haya podido ignorar (art. 4.2.1). El estándar de la persona razonable apunta a un esperado entendimiento usual en personas de la misma condición, es decir, con los mismos conocimientos y experiencia técnica o en los negocios.

Debemos señalar, para concluir, que esta búsqueda de desentrañar la intención común de las partes debe ser cuidadosa para no perjudicar a los terceros, quienes podrían verse afectados por manifestaciones culposas de los contratantes.

40. La interpretación restrictiva

El artículo 1062, primera parte, prevé que *cuando por disposición legal o convencional se establece expresamente una interpretación restrictiva, debe estarse a la literalidad de los términos utilizados al manifestar la voluntad.*

Es lo que se ha dado en llamar "interpretación auténtica", que incluye no solo la hipótesis de que la ley haya dado a los términos un significado determinado, sino también a las definiciones que las partes hayan establecido de ellos. De esta forma, se aclara la terminología que pueda generar dudas.

Normalmente, esta interpretación se fija en el propio contrato; sin embargo, no existe problema en que ella se asiente en uno nuevo. Pero, en este caso, el nuevo contrato no puede afectar los derechos adquiridos por los terceros como consecuencia del primero.

Esta disposición no es aplicable a las obligaciones del predisponente y del proveedor en los contratos por adhesión y en los de consumo, respectivamente (art. 1062, 2ª parte); ello en consideración a la protección que debe darse a adherentes y consumidores.

41. La interpretación gramatical

Las palabras empleadas en el contrato deben entenderse en el sentido que les da el uso general (art. 1063, párr. 1º, 1ª parte); esto es que el significado común de las palabras prevalece sobre el sentido técnico. Este punto hace una aplicación expresa de la lealtad, que —como hemos recordado antes— es un concepto integrante del principio general de la buena fe. El hombre medio usa las palabras en sentido común y no técnico, incluso —a veces— de manera impropia, aunque conforme con un uso vulgar, y no es posible que las diferencias culturales o de poder negociador sean reafirmadas mediante la prevalencia del sentido técnico en desmedro del débil jurídico. Es esencial hablar claro; quien no lo hace debe cargar con las consecuencias.

Por ello, por el valor que tienen las palabras usadas es que cuando el convenio es claro y preciso no puede ser modificado por interpretaciones sobre la base del espíritu de las cláusulas, intención presunta de las partes o las finalidades perseguidas, pues las palabras se corresponden en sí mismas con la realidad que designan y además, por regla general, traducen con fidelidad el pensamiento. Quien pretenda que la voluntad contractual difiere de la que surge claramente del contrato o que los términos usados tienen un significado distinto del que se desprende de su acepción común, debe producir una prueba harto contundente; de lo contrario, debe prevalecer la interpretación conforme a la claridad aludida.

Pero, desde luego, si el contrato se refiriera a un tema técnico y ambas partes fueran idóneas en él, deberá entenderse que las palabras usadas han sido tomadas en el sentido propio con que se las utiliza en esa especialidad; lo mismo sucede cuando la propia ley, el acuerdo de las partes o los usos y prácticas del lugar de celebración, atribuyen a las palabras un significado específico (art. 1063, párr. 1º, 2ª parte). Estas mismas reglas, debe añadirse, se aplican a las conductas, signos y expresiones no verbales con los que el consentimiento se manifiesta (art. 1063, párr. final).

Una cuestión particular, pero interesante, está dada por el uso de palabras o expresiones específicas, seguidas por palabras o expresiones genéricas. Esta expresión o palabra genérica no puede ser interpretada en sentido amplio sino acotada a la palabra o expresión específica que la precede. Así, si en un contrato de seguro, el riesgo cubierto es el incendio o naufragio de una nave u otro peligro, este "otro peligro" solo puede ser entendido como un riesgo relativo a la navegación.

Un problema particular se plantea con los contratos redactados en diferentes lenguas (es el caso, por ejemplo, de que se firmen diversos ejemplares en distintos idiomas). En este supuesto, si las partes no han dado prioridad a un idioma en particular, dando autenticidad a todas las versiones, parece razonable presumir que, en caso de discrepancia, las partes quieren ser leídas en la lengua en que se hizo la primera redacción (conf. art. 4.7, Principios Unidroit).

42. La interpretación contextual o sistemática

Las cláusulas contractuales no pueden ser interpretadas aisladamente sino *unas por medio de las otras, y atribuyéndoles el sentido apropiado al conjunto del acto* (art. 1064). La solución es absolutamente lógica, pues el contrato es un todo inescindible e indivisible. Además, son las mismas personas que se obligaron, por lo que resulta absurdo pensar que se pueda separar cada idea, toda vez que las cláusulas están encadenadas unas con otras. La pretensión de hacer prevalecer una palabra o frase aislada, que no guarda coherencia con el resto del contrato, altera su sentido y espíritu que es uno solo, y constituiría una clara arbitrariedad, violatoria a su vez del principio general de la buena fe. Las partes no pueden ampararse en cláusulas que las favorecen y desechar las perjudiciales.

Es necesario añadir que cada cláusula arrancada del conjunto y tomada en sí misma puede tener un significado inexacto; solamente la correlación armónica de cada una con

las otras y teniendo en cuenta la luz que proyectan armónicamente permite desentrañar el significado efectivo de cada una y de todas tomadas en conjunto.

Debe señalarse, sin embargo, que esta interpretación sistemática no es aplicable a los contratos con cláusulas predisuestas, porque el grueso de contrato, al estar prerredactado, responde al querer de uno solo de los contratantes. Por ello, en estos casos, prevalece la cláusula especial sobre lo predispuesto. Cabe recordar que el artículo 987 establece que *las cláusulas ambiguas predisuestas por una de las partes se interpretan en sentido contrario a la parte predisponente*.

43. El principio de la conservación del negocio

El artículo 1066 dispone que *si hay duda sobre la eficacia del contrato, o de alguna de sus cláusulas, debe interpretarse en el sentido de darles efecto*. Y añade que *si esto resulta de varias interpretaciones posibles, corresponde entenderlos con el alcance más adecuado al objeto del contrato*.

Resulta absurdo pensar que las partes han celebrado un negocio jurídico tendiente a que no produzca efectos, como resultaría de la nulidad posible. Lo razonable es que han querido producir efectos jurídicos, y de allí la validez que debe presumirse. Lo mismo cabe decir de ciertas cláusulas convenidas; sería un sinsentido pensar que han sido pactadas para no darle valor alguno.

La norma avanza también en otra dirección: si hay varias interpretaciones posibles (como se ve, no se plantea una hipótesis de ineficacia), deberá preferirse aquella que se adecue mejor al objeto contractual.

44. La naturaleza y finalidad del contrato

El artículo 1065 establece que *cuando el significado de las palabras interpretado contextualmente no es suficiente, se debe tomar en consideración... c) la naturaleza y finalidad del contrato*.

Se trata de una regla interpretativa, que a su vez deriva del principio general de la buena fe. Para los Principios Unidroit, la naturaleza y la finalidad del contrato constituyen una circunstancia relevante en la interpretación del contrato (art. 4.3).

Es fundamental determinar qué contrato se ha querido celebrar, calificarlo, más allá del nombre que se le haya dado, pues la interpretación deberá ser acorde con eso querido, esto es con la finalidad tenida en cuenta por las partes. El nombre que las partes le den al contrato es de escasa importancia. Lo que importa es que el juez lo califique jurídicamente, lo que le permitirá desentrañar su naturaleza, clasificarlo entre las categorías jurídicas existentes, determinar las normas jurídicas que han de aplicarse, e interpretarlo correctamente. El ejemplo típico es el contrato de comodato celebrado entre dos partes, que en verdad encubre una verdadera locación, usándose aquel formato para eludir las reglas imperativas que gobiernan a este último.

Por otra parte, para interpretar un contrato resulta necesario conocer el fin práctico y económico tenido en cuenta por las partes. Ello es así, pues el contrato es el medio adecuado para que ellas alcancen el fin querido, con lo que se advierte que teniendo en cuenta el fin querido podremos dar el significado adecuado al contrato.

Asimismo, este tener muy en cuenta el fin querido por las partes nos conecta con la llamada teoría de la causa que ha tendido a imponerse en el derecho comparado. El neocausalismo, hoy sostenido mayoritariamente, hace referencia a un fin económico, objetivo, y a otro fin subjetivo o motivo determinante. En este caso, resulta esencial el fin económico, que demuestra que todo contrato persigue el objetivo de producir la circulación de bienes.

45. La conducta de las partes

El artículo 1065 establece que *cuando el significado de las palabras interpretado contextualmente no es suficiente, se debe tomar en consideración... b) la conducta de las partes, incluso la posterior a su celebración.*

La norma causa cierta perplejidad. De su redacción, pareciera que lo importante es la conducta anterior; de allí que se dice que incluso debe considerarse la conducta posterior. Y, en verdad, lo realmente trascendente es la conducta posterior. La anterior solamente deberá ser tenida en cuenta con mucha precaución.

Con mejor criterio, el Código de Comercio derogado establecía que *los hechos de los contrayentes, subsiguientes al contrato, que tengan relación con lo que se discute, serán la mejor explicación de la intención de las partes al tiempo de celebrar el contrato* (art. 218, inc. 4º). Lo mismo han destacado los Principios Unidroit, que disponen que los actos realizados por las partes con posterioridad a la celebración del contrato son circunstancias relevantes de la contratación (art. 4.3). La idea es clara: si las partes se han comportado de determinada manera, es porque así creyeron que cumplían sus obligaciones y ejercían sus derechos conforme a lo convenido. Esa conducta, muchas veces, revela lo querido de manera más clara que lo escrito en el contrato, pues traduce en hechos lo que puede resultar dudoso en la palabra. Pretender lo contrario a lo que se interpreta del comportamiento efectuado es contrario al principio general de la buena fe que debe gobernar la relación contractual.

Es claro que las conductas de los contratantes a los que alude la norma son aquellos actos voluntarios, pues los ejecutados sin discernimiento, intención o libertad no constituyen un acto jurídico y, por tanto, no producen por sí obligación alguna (arts. 259 y 260).

Ahora bien, debe destacarse que la conducta que verdaderamente importa y debe considerarse es aquella que perjudica al que la ha realizado. En efecto, si se considerara la conducta que beneficia a quien la alega, las partes encontrarían una vía sencilla para torcer la recta interpretación del contrato, ejecutando ciertos hechos que más tarde se harán valer en la contienda judicial en su propio provecho.

Pasemos ahora a la conducta anterior a la celebración del contrato. ¿Resulta o no relevante a los efectos de interpretarlo? La cuestión no es sencilla. Por un lado, está claro que si lo pactado es distinto de lo obrado con anterioridad, ello demuestra que finalmente las partes acordaron algo diferente, por lo que ese comportamiento anterior no tiene relevancia. Sin embargo, en los casos de duda, cuando el contrato ha dejado algunas lagunas, esos vacíos bien pueden llenarse con las conductas anteriores de las partes, que reflejan una unidad de obrar y conforman, además, las bases de entendimiento que en su momento fueron consideradas para celebrar el contrato.

Esas negociaciones han dado lugar a las tratativas precontractuales y a trabajos preparatorios, e, incluso, pueden haber derivado en un contrato preliminar. Incluso, no es un dato menor a considerar la situación particular de los sujetos contratantes, pues ella revela lo que buscaban conseguir con el contrato y los propósitos que los guiaron.

46. Las circunstancias del caso

El artículo 1065 establece, también, que *cuando el significado de las palabras interpretado contextualmente no es suficiente, se debe tomar en consideración: a) las circunstancias en que se celebró, incluyendo las negociaciones preliminares.*

Para interpretar un contrato es necesario considerar los hechos producidos al tiempo de la celebración, la situación existente en ese momento, que en definitiva denotan la intención de las partes a la época de contratar.

En efecto, similares palabras o conductas pueden reflejar distintas intenciones. Veamos un ejemplo: si a una persona se le rompe el vehículo mientras circula por una ruta, y acepta que otra persona lo arregle, habrá contrato de servicios o no según si el

que hace la reparación es alguien que trabaja prestando ese servicio en la ruta o si el que hace la reparación es un amigo que viajaba con él.

Por otra parte, las negociaciones preliminares son importantes, como se ha dicho antes, para determinar lo pretendido por las partes.

47. El principio de coherencia o confianza, o teoría de los actos propios

El artículo 1067 establece que *la interpretación debe proteger la confianza y la lealtad que las partes se deben recíprocamente, siendo inadmisibles la contradicción con una conducta jurídicamente relevante, previa y propia del mismo sujeto.*

La idea es clara. Se trata de que la interpretación contractual tenga en cuenta la confianza que ha despertado una de las partes en la otra, con su comportamiento, rechazando su contradicción. Se trata de la recepción de la teoría de los actos propios que, en otra ocasión, hemos definido como la regla de derecho, derivada del principio general de la buena fe, que sanciona como inadmisibles toda pretensión lícita pero objetivamente contradictoria respecto del propio comportamiento anterior efectuado por el mismo sujeto.

Más allá de la claridad de la idea, a nuestro entender existen dos fallas que deben puntualizarse.

La primera, que la definición que se da en el artículo 1067 es incompleta. En efecto, la teoría de los actos propios exige no solo que la conducta vinculante (la que ha despertado la confianza en el otro sujeto) sea jurídicamente relevante; exige que ella sea eficaz. En efecto, si la conducta vinculante es inválida o es ineficaz en sí misma o es ilícita o es contraria a las buenas costumbres o a la moral, se la puede contradecir, sin violar el principio de coherencia.

La segunda es una falla metodológica. La teoría de los actos propios no es solo aplicable a los contratos; por el contrario, es aplicable a toda situación o relación jurídica, aunque no sea un contrato. De hecho, tradicionalmente se le ha reconocido una función supletoria en el ámbito contractual. Por ello, hubiera sido más acertado incluir esta norma en el título preliminar.

48. Los usos, prácticas y costumbres sociales

Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho (art. 1º).

La interpretación del contrato debe tener en cuenta los usos, prácticas y costumbres sociales. Por lo tanto, a menos que se trate de una situación reglada legalmente, si las partes contratantes pretenden apartarse de lo que es habitual –según esos usos, prácticas y costumbres– deberán expresarlo con claridad. Un ejemplo de ello es la costumbre en algunos lugares de la Argentina de que el postor en un remate de hacienda preste su asentimiento con un simple movimiento de cabeza, lo que no ocurre en otras subastas, y no podrá prescindirse de esta costumbre. Es preciso aclarar que los usos, prácticas y costumbres obligan si las partes los conocen o debieran conocerlos con una diligencia media, salvo que su aplicación sea irrazonable (conf. Principios Unidroit, art. 1.8.2).

Ahora bien, cabe interrogarnos: ¿Cuál es el lugar que debe importar para considerar los usos, prácticas y costumbres: el de ejecución o el de celebración del contrato? Nos inclinamos por el lugar de celebración, máxime si las partes viven en el mismo sitio. En este caso, parece evidente que los usos y costumbres tenidos en cuenta son los de ese lugar, pues los matices o significados que se pueden atribuir corresponden con los que ellos conocen, es decir, con los del lugar que habitan.

A ello, añádase que el artículo 964, al referirse a la integración del contrato, considera los usos y prácticas del lugar de celebración en cuanto sean aplicables.

49. La interpretación integradora

El artículo 964 establece que *el contenido del contrato se integra con: a) las normas indisponibles, que se aplican en sustitución de las cláusulas incompatibles con ellas; b) las normas supletorias; c) los usos y prácticas del lugar de celebración, en cuanto sean aplicables porque hayan sido declarados obligatorios por las partes o porque sean*

ampliamente conocidos y regularmente observados en el ámbito en que se celebra el contrato, excepto que su aplicación sea irrazonable.

Muchas veces resulta necesario llenar las lagunas del contrato, las que inexorablemente existen, pues es imposible que las partes puedan prever todas las contingencias que puedan acaecer, y para ello debe recurrirse a la llamada interpretación integradora, que ha recibido consagración legislativa en la norma transcrita. La misma idea de interpretación integradora está receptada en la segunda parte del artículo 961, cuando, refiriéndose a la buena fe, establece que los contratos *obligan no sólo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor.*

La interpretación integradora refleja que el contrato está conformado por cláusulas expresamente pactadas por las partes, por cláusulas imperativas o indisponibles que no pueden ser eludidas por ellas, por cláusulas que se desprenden de la legislación supletoria (cláusulas legales que pudieron ser verdaderamente conocidas por las partes, habiendo omitido mencionarlas en el contrato justamente por la aplicación subsidiaria de ellas, o que pudieron ser ignoradas aunque son aplicables plenamente por imperio legal) y por los usos y prácticas. Todas estas cláusulas tienen valor jurídico.

No se trata entonces de interpretar exclusivamente las cláusulas escritas en el contrato sino de interpretarlas de manera armónica con las que prevé la legislación supletoria y la costumbre, lo que denota la posibilidad de influirse recíprocamente, amén de permitir al juez establecer la verdadera extensión de las obligaciones. Asimismo, es posible integrar el contrato considerando lo previsto por las partes y haciendo derivar de ello lo que ellas mismas presumiblemente hubieran manifestado de haber previsto el punto en cuestión expresamente.

Particularmente importante es la interpretación integradora en dos supuestos: a) frente a la nulidad parcial, y b) en los casos de aplicación de normas imperativas o indisponibles. En los casos de nulidad parcial, el juez deberá integrar el contrato para darle plenos efectos, integración esta que se hará mediante la aplicación de normas imperativas en sustitución de las nulas, aplicación de normas supletorias, incorporación de los usos y costumbres, y presencia del principio general de la buena fe. Por otra parte, hay casos en que deben aplicarse reglas de carácter imperativo, como ocurre con los deberes secundarios de conducta que surgen de la buena fe, las garantías legales y las cargas, y también con las condiciones impuestas por el orden público que provocan el reemplazo de las normas contractuales que las contradigan o ignoren.

Pero, además, existen supuestos en que la propia ley obliga a dejar sin efecto ciertas cláusulas e integrar el contrato con las normas imperativas que ella impone, como ocurre con el plazo de locación inmobiliaria que, si fuera inferior a los mínimos legales, carece de valor alguno, a menos que el locatario ya tenga la tenencia de la cosa (art. 1198).

En la integración del contrato habrá que tener en cuenta, además, si el contrato es nominado o innominado. Para los contratos nominados deberá recurrirse a las pautas fijadas en el ya transcrito artículo 964; para los innominados, deberá acudir, además, a las normas generales sobre contratos y obligaciones, a los usos y prácticas del lugar de celebración, y a las disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines que sean compatibles y se adecuen a su finalidad (art. 970, incs. b), c) y d)).

En todos los casos, deben respetarse las reglas de prelación normativa establecidas en el artículo 963; esto es que si concurren disposiciones del Código Civil y Comercial y de alguna ley especial, las normas se aplican con el siguiente orden de prelación: i) las normas indisponibles de la ley especial y del Código; ii) las normas particulares del contrato; iii) las normas supletorias de la ley especial, y iv) las normas supletorias del Código.

50. La interpretación en los contratos de consumo, por adhesión y conexos

a) Los contratos de consumo

En el campo de los contratos de consumo, es fácilmente advertible la existencia de una disparidad de poder negocial (no solo económica, sino también jurídica), en tanto el

proveedor tiene la facultad de establecer las condiciones contractuales, lo que parece poner en evidencia un claro signo conmovedor del principio de la autonomía de la voluntad de los contratantes.

El Código Civil y Comercial dispone que *las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable*. Y añade que *en caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor* (art. 1094).

Por otra parte, la legislación especial ha procurado compensar esta diferencia en el poder negociador, con cierta protección del consumidor, que se traduce en la sanción de normas tuitivas. La ley 24.240 –llamada de defensa del consumidor–, que es de orden público (con todo lo que ello implica), ha fijado también ciertas reglas de interpretación. Estas cuestiones serán analizadas más adelante (véase nro. 347 y ss.).

b) Los contratos por adhesión

Nos hemos referido a estos contratos con anterioridad.

Solamente nos hemos de limitar a recordar que

i) Las cláusulas ambiguas deben ser interpretadas en sentido adverso a quien las redactó (art. 987). La solución constituye una clara aplicación del principio general de la buena fe. La regla protege al adherente, quien no tiene otra opción que adherir a la propuesta redactada por la otra parte o no contratar, y por ello es lógico que quien redactó el contrato, lo hizo sin claridad, con ambigüedad o términos abusivos, se haga cargo de las consecuencias indeseables de tal tipo de redacción. Pensamos que esta idea es, incluso, aplicable al contrato paritario, si es factible determinar quién redactó la cláusula ambigua; en esta línea, los Principios Unidroit disponen que si de los términos de un contrato dictados por una de las partes no son claros se preferirá la interpretación que perjudique a dicha parte (art. 4.6).

ii) Las cláusulas especiales prevalecen sobre las generales, aunque estas no hayan sido canceladas (art. 986).

iii) Las cláusulas manuscritas o mecanografiadas prevalecen sobre las impresas, pues constituyen cláusulas especiales.

iv) En los contratos predispuestos, las cláusulas incorporadas prevalecen sobre las preexistentes.

v) Los usos y costumbres no pueden ser valorados como en los contratos paritarios, pues pueden responder a prácticas abusivas del predisponerte o pueden modificar la economía del negocio; de allí que el artículo 964, inciso c), disponga que el contrato se integra con los usos y prácticas, en cuanto sean aplicables.

CAPÍTULO XVI - EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS

§ 1.– Causales

A.

— CUMPLIMIENTO

51. Cumplimiento

Los contratos se extinguen naturalmente por el cumplimiento de las obligaciones que los contratantes han asumido. Así, por ejemplo, en la compraventa, el contrato se extingue con la entrega de la cosa por una parte, y el pago del precio, por la otra; en el contrato de obra, por la realización y entrega de la obra por el empresario y el pago de su precio por el dueño, etcétera.

El cumplimiento puede ser exigido forzosamente (art. 730, inc. a)] y, en ciertos casos, se puede hacer cumplir la obligación por un tercero (art. 730, inc. b)].

En los contratos de consumo, expresamente se otorga al consumidor la facultad, entre otras, de exigir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que ello fuera posible, y sin perjuicio –claro está– del derecho a accionar por los daños y perjuicios que correspondan (art. 10 bis, ley 24.240, ref. por ley 24.787).

Sin embargo, no debe creerse que con el cumplimiento de las prestaciones se extinguen totalmente las obligaciones contractuales. Así, en los contratos onerosos el que entregó la cosa debe todavía la garantía de saneamiento.

B.

— IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO

52. Concepto

También se extinguen los contratos por la imposibilidad de cumplir la prestación.

El artículo 955 establece que tal imposibilidad debe ser sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva; esto es, que la imposibilidad sea posterior al nacimiento de la obligación, que importe un impedimento insuperable para cualquier persona y que no sea transitoria.

C.

— NULIDAD

53. Noción

La nulidad es una sanción prescripta en la ley, que priva a los contratos de sus efectos normales en razón de un vicio originario, es decir, anterior o concomitante con la celebración del acto. Aquí solo aludiremos a un problema específico de los contratos. El principio general en materia de nulidades es que la nulidad de una cláusula no entraña la nulidad de todo el acto si las cláusulas fueran separables (art. 389, párr. 2º). Se trata de un supuesto de nulidad parcial. En este caso, el juez deberá integrar el contrato, si fuere necesario, de acuerdo con su naturaleza y con los intereses que razonablemente puedan considerarse perseguidos por las partes (art. 389, párr. 3º). Debe resaltarse que el deber del juez de integrar el contrato solo existe si es necesario para la finalidad del contrato. Así, una tasa de interés fijada en valores usurarios puede ser anulada lisa y llanamente, lo que resulta particularmente importante en los contratos por adhesión, para evitar abusos del predisponente.

Pero si las disposiciones no son separables, porque el acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad, debe declararse la nulidad total del contrato (art. 389, párr. 2º).

Entre los casos de cláusulas separables, cuya nulidad no invalida todo el acto, cabe citar: a) El de las cláusulas nulas sustituidas *de iure* por normas indisponibles. Ejemplo:

la convención que fije al contrato de locación un término menor que el que determina el artículo 1198 es de ningún valor; la relación jurídica mantiene toda su vigencia y debe sustituirse la cláusula nula por otra acorde con el plazo indicado en esa norma. b) El de la cláusula accesorio, cuando resultare evidente de una interpretación contextual que, aun sin ella, el contrato se habría celebrado de todas maneras. c) Finalmente, hay que admitir que la parte afectada por la nulidad de una cláusula tiene derecho a mantener la validez del resto del contrato, si aun así, le conviniera: en ese caso, nada justificaría la nulidad total. Bien entendido que debe tratarse siempre de partes separables, como dice el artículo 389, pues si se tratara de una cláusula fundamental relativa al objeto, la causa, etc., es inconcebible la nulidad parcial.

D.

— CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN

54. Noción

La prescripción liberatoria es una figura jurídica que considera dos cuestiones: la inacción del titular de un derecho y el transcurso del tiempo fijado por la ley. La prescripción no extingue el contrato, pero sí extingue la acción derivada de él, extinción que se produce si ha transcurrido el plazo legal y el titular del derecho no lo ha reclamado. Como se puede advertir, por esta vía se hace perder eficacia jurídica al contrato. Ello no obsta a que si se cumple espontáneamente una obligación prescripta, el cumplimiento queda firme y es irrepitable (art. 2538).

La caducidad tiene efectos más radicales: no solo hace perder la acción, extingue también el derecho no ejercido (art. 2566). Así, la responsabilidad por defectos ocultos en un inmueble caduca a los tres años de recibido (art. 1055, inc. a)], y ya no podrá reclamarse aun cuando el vicio se haga evidente más tarde.

E.

— CONFUSIÓN

55. Noción

Hay confusión cuando se reúne en una misma persona la calidad de deudor y acreedor, y en un mismo patrimonio (art. 931). En tal caso la obligación queda extinguida. Es claro, entonces, que si se reúnen en una misma persona los derechos y obligaciones de dos contratantes (como ocurriría si el comprador de un inmueble viene a ser el único heredero del vendedor), el contrato se extingue.

F.

— TRANSACCIÓN

56. Noción

La transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio, o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas (art. 1641). Ahora bien, aun cuando la transacción es un contrato, lo que las partes procuran no es generar derechos ni transmitirlos, sino declararlos o reconocerlos. Mediante la transacción, las partes abandonan un estado de cierta incertidumbre jurídica e ingresan en otro de plena certeza, con clara determinación de sus derechos. De esta manera se extinguen aquellas obligaciones que eran dudosas.

G.

H.

— RENUNCIA

57. Noción

La renuncia es una declaración de voluntad por la cual una persona abandona un derecho y lo da por extinguido. Por ello, en la medida en que la renuncia no esté prohibida y solo afecte intereses personales, es posible que ambas partes o una de ellas renuncien a los derechos conferidos en un contrato, extinguiéndose así las obligaciones oportunamente creadas.

58. Planteo del tema

Como regla, la muerte de las partes o de una de ellas no provoca la extinción del contrato.

Por el contrario, *los efectos del contrato se extienden, activa y pasivamente, a los sucesores universales* (art. 1024), con lo cual, los herederos vienen a ocupar el lugar de quien ha fallecido y quedan obligados a cumplir con las disposiciones establecidas en el contrato y a ejercer los derechos allí conferidos.

Sin embargo, esta regla tiene sus excepciones. En efecto, el propio artículo 1024 establece que no se transmiten a los herederos las obligaciones que sean inherentes a la persona del causante, o cuando la transmisión sea incompatible con la naturaleza de la propia obligación o esté prohibida por una cláusula o por la ley (véase nro. 202).

I.— RESCISIÓN

59. Rescisión bilateral. Concepto y efectos

La rescisión bilateral es un acuerdo de voluntades por el cual se deja sin efecto un contrato. Por ello se la llama también *distracto*. Puesto que el acuerdo de voluntades ha podido crear un vínculo jurídico, puede también aniquilarlo o extinguirlo.

Los efectos de la rescisión bilateral dependen de la voluntad de las partes, aunque si nada se conviene, solamente produce efectos para el futuro (art. 1076). En otras palabras, las partes pueden acordar que el contrato originario quede sin efecto retroactivamente, con obligación de las partes de restituirse mutuamente todo lo que hubieran recibido la una de la otra; o bien pueden acordar que el contrato deja de producir sus efectos en adelante, quedando firmes los efectos ya producidos. Debe decirse, sin embargo, que la retroactividad resultante de una rescisión bilateral no puede perjudicar nunca los derechos que los terceros hubieran adquirido en el ínterin como consecuencia del contrato originario (art. 1076, *in fine*).

60. Rescisión unilateral. Concepto y efectos

La rescisión unilateral no importa un acuerdo de voluntades; por el contrario, una sola de las partes, por propia voluntad, está facultada a poner fin a las relaciones contractuales, total o parcialmente (art. 1077). Esta facultad excepcional es reconocida por la ley en ciertos contratos; así, por ejemplo, en el contrato de trabajo, que puede ser rescindido por voluntad unilateral del obrero o del patrón; en el contrato de obra el dueño puede desistir por su sola voluntad (art. 1261); en el contrato de locación, el locatario puede rescindir unilateralmente (la norma habla erróneamente de resolución anticipada) en la medida en que dé cumplimiento con las pautas fijadas en el artículo 1221, etc. Esta rescisión unilateral pone término a las relaciones contractuales a partir del momento en que la voluntad se ha manifestado; pero no afecta los efectos anteriores del contrato, es decir, no tiene retroactividad, salvo pacto en contrario (art. 1079, inc. a)).

También es posible que las partes hayan pactado la posibilidad de rescindir el contrato de manera unilateral (art. 1077). En este caso, la facultad rescisoria no puede ser ejercida abusiva, desconsiderada o desmedidamente, y ninguna de las partes, en caso de indeterminación del plazo de vigencia del contrato, está autorizada para hacer cesar abruptamente la relación, salvo que un *casus* le imponga hacerlo o hubiere acaecido una actividad francamente culpable o dolosa de una de las partes. También en este caso, los efectos son solo para el futuro, salvo estipulación en contrario (art. 1079, inc. a)).

La ley nada dice de la situación de los terceros ante un caso de rescisión unilateral, legal o convenida. La omisión quizás se deba a que se prevé como regla que los efectos solo serán para el futuro. Sin embargo, no puede olvidarse que la propia norma deja a salvo la posibilidad de convenir que los efectos se retrotraigan hacia el pasado; en este caso, parece claro que no pueden afectarse los derechos de los terceros (arg. art. 1021).

61. Concepto y efectos

Establece el artículo 1077 que el contrato puede ser extinguido total o parcialmente por la declaración de una de las partes, mediante revocación, en los casos en que el mismo contrato o la ley le atribuyan esa facultad. Y más adelante, se dispone que, como regla, produce efectos solo para el futuro (art. 1079, inc. a)).

Da la sensación que la norma ha considerado la revocación en el sentido que se le da en ciertos contratos, como es el caso de la revocación del mandato (art. 1329, inc. c)); pero en rigor, ese es un supuesto de rescisión unilateral. En efecto, se trata de la facultad que le confiere la ley para dejar sin efecto un contrato, de manera unilateral y sin causa justificante alguna que deba probar. Por ello es que sus efectos se producen no retroactivamente, sino a partir del momento en que el mandato fue revocado.

En su significado estricto, la idea de revocación está unida a la de liberalidad: se revoca una donación, un testamento. Importa un acto de voluntad por el cual se deja sin efecto la liberalidad. Limitándonos ahora al campo de los contratos (en el derecho sucesorio, la solución es distinta), diremos que la revocación exige una causa jurídica que la justifique; así, por ejemplo, será necesario que medie ingratitud del donatario o incumplimiento por éste de los cargos que le fueron impuestos (art. 1569).

K.

— RESOLUCIÓN

62. Concepto y efectos

La resolución no es el resultado de un nuevo acuerdo de voluntades (como ocurre en la rescisión bilateral), sino que supone la extinción del contrato por virtud de un hecho posterior a la celebración, hecho que a veces es imputable a la otra parte (como es, por ejemplo, el incumplimiento) o que puede ser extraño a la voluntad de ambos (como ocurre en ciertos supuestos de condiciones resolutorias). La resolución del contrato puede operar *ipso iure* (como sucede en la condición resolutoria) o bien puede requerir la manifestación devoluntad de la parte interesada en ella (como ocurre en la que se funda en el arrepentimiento o en el incumplimiento de la contraria).

La resolución deja sin efecto el contrato entre las partes, de manera retroactiva (art. 1079, inc. b)); su consecuencia es volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la celebración del contrato. En este punto, sus efectos son semejantes a los de nulidad; pero se diferencia claramente de esta en que el hecho que provoca la resolución es siempre posterior al contrato, en tanto que el que da lugar a la nulidad, debe ser anterior o concomitante con la celebración.

Respecto de los terceros, deberá diferenciarse según si se trata de adquirentes a título oneroso o gratuito, y si son de buena o mala fe. La norma antes citada protege solo el derecho adquirido a título oneroso por terceros de buena fe.

El régimen de los contratos de consumo presenta en este tema algunas particularidades. Ante el incumplimiento del cocontratante, el consumidor tiene derecho —entre otros— a resolver el contrato, pudiendo exigir la restitución de lo pagado, sin perjuicio de los efectos producidos, considerando la integridad del contrato. Además de ello, está facultado para accionar por los daños y perjuicios que correspondan (art. 10 bis, ley 24.240, ref. por ley 24.787).

Tienen especial importancia como causa de resolución el pacto comisorio (véanse nros. 239 y ss.), la seña (véanse nros. 231 y ss.), la teoría de la imprevisión (véanse nros. 331 y ss.) y la frustración del fin contractual (véanse nros. 336 y ss.).